

1500328-10.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1500328-10.2022.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500328-10.2022.8.26.0542

Controle: 2022/000265

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

VALDILEY CARRERO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

VALDILEY CARRERO, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, porque, em 4 de fevereiro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Vicente de Carvalho, Vila Osasco, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, transportou, entre Estados da Federação: 1.001,12g de cocaína, substância entorpecente, capaz de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais civis passavam pelas imediações da Praça Henrique de Nicol, ocasião em que avistaram veículo ali parado, com duas pessoas em seu interior, tendo o condutor esboçado nervosismo, com a aproximação policial, ensejando a abordagem.

Indagado, Valdiley admitiu aos agentes policiais que transportava drogas em uma mochila que estava no porta-malas do veículo. Esclareceu que residia em Garapari-ES e que receberia R\$ 2.000,00 para transportar a droga de Governador Valadares-MG até o Estado de São Paulo.

Em revista pelo automotor, os policiais civis localizaram um tijolo de cocaína. Danielle Neto de Castro, esposa de Valdiley e que estava no banco do passageiro, negou envolvimento com a mercancia de entorpecentes, o que foi corroborado por ele. A denúncia foi oferecida, sendo regularmente notificado Valdiley (fls. 165). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 150/151) e, não havendo causas para a sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 12 de abril de 2022 (fls. 150/151). Valdiley foi citado (fls. 172).

Em instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 201/203), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 204).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 205).

Em sede de memoriais escritos, a Dra. Promotora de Justiça pleiteou pela procedência da ação-penal com a consequente condenação de Valdiley Carreiro nos termos da denúncia (fls. 208/212).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 para o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como pela incidência do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (fls. 216/225).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva consubstancia-se em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo pericial de constatação (fls. 19/21), laudo pericial químico-toxicológico (fls. 110/112), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 201/203) e, especialmente, pela confissão judicial de autoria (fls. 204).

Perante a D. Autoridade Policial, perante a D. Autoridade Policial, Valdiley se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 11/12).

Em Juízo Valdiley confessou a prática delitiva. Declarou que passava dificuldade financeira e um pessoal lhe ofereceu para trazer drogas de Governador Valadares para Osasco. Aceitou e convidou sua esposa para fazerem compras no Brás a fim de que revendessem as roupas, porque ela estava sem trabalho. Essa foi a primeira e última vez que se envolveu com tráfico de entorpecentes. Sempre trabalhou, nunca ficou parado. Já trabalhou como pedreiro, Uber, garçom. Declara seu arrependimento (fls. 204).

Infere-se que a confissão representa idôneo liame entre a autoria e o evento perpetrado, encontrando-se corroborada pelas demais provas produzidas. Deve, pois, ser considerada sincera. Neste sentido:

“Confissão Judicial - Ausência de circunstância que evidenciem insinceridade - Suficiência - Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”. (Ap. 470.903-2-SP - 8a C. - TACrim - j. 08.10.87 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida).

Outrossim, não comprovado o alegado estado de necessidade, inviável é a aplicação do artigo 24, do Código Penal.

A testemunha Policial Civil Vivaldo declinou que estava trabalhando com seu parceiro quando avistou veículo com tarjeta de outro estado e o motorista apresentou nervosismo, olhando muito. Fizeram a abordagem e ele não sabia explicar o que fazia ali. Quando ele sentiu que o veículo seria revistado, resolveu confirmar que estava transportando drogas. O veículo foi revistado e no porta-malas localizado uma sacola plástica que estava com um sabugo de milho e um tijolo de 5 Kg de cocaína. Segundo ele, havia pegado a droga em Minas Gerais e entregaria para um desconhecido em Osasco (fls. 201).

A testemunha Policial Civil Luiz Antônio asseverou que estava retornando de diligências com seu parceiro quando viu o veículo Ônix com um casal no interior parado em uma praça. Pelo emplacamento, o veículo era de Minas Gerais. Ao passar pelo veículo, viram que o motorista expressou nervosismo. Fizeram a volta e ele olhou novamente. Decidiram fazer a abordagem e ambos desceram do veículo.

Questionado, o motorista disse que era do Espírito Santo e se enrolou ao dizer o que fazia aqui. Então disse que estava trazendo drogas no porta-malas. Ele abriu o porta-malas e havia uma bolsa de pano preta com um sabugo de milho e um tablete de cocaína. Ele mencionou que conhecia indivíduos no Estado dele e aceitou a proposta de trazer drogas para São Paulo, sendo que receberia dois R\$ 2.000,00. Então, ele foi para Governador Valadares e convidou a esposa para passear em São Paulo e na rodoviária pegou o veículo que lhe foi dado para trazer as drogas para Osasco e recebeu R\$ 1.000,00. A moça informou que veio a convite dele e que não sabia qual era o conteúdo que ele traria de encomenda para São Paulo. Ela veio com intenção de fazer compras no Brás (fls. 202).

Tem-se, portanto, que os testemunhos policiais demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam as indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, tanto na fase extrajudicial quanto judicialmente, no aspecto principal. Inclusive, estando corroborados pela confissão judicial do acusado. É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório.

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial” (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94)

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.)

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Valdiley. Ele foi abordado após apresentar comportamento suspeito, olhando reiteradamente para a viatura policial. Indagado, ele confirmou que estava transportando droga de Governador Valadares-MG a Osasco-SP, aliás como por ele confessado judicialmente. Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

O acusado foi denunciado por transportar entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

“Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa” (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que a condição de usuário não exclui a traficância. Ainda, a quantidade de entorpecente apreendida, 5 Kg de cocaína não é condizente com a condição de mero usuário.

Ainda, configurado o tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação, observando-se que Valdiley confessou ter recebido o entorpecente em Governador Valadares-MG, trazendo-o para o Estado de São Paulo, sendo abordados em Osasco-SP. Incide, portanto, o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Conclui-se, pois, pela procedência da presente ação penal com a consequente condenação de Valdiley Carreiro por incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. Passo à dosimetria da pena.

Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

Faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, como é cediço, ao Magistrado não é dado transgredir os limites que a lei fixa para as penas, salvo nos casos em que tal faculdade é expressamente outorgada. Assim, inadmissível é a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda quando se cuide de agente confesso judicialmente:

"Na aplicação da pena, as circunstâncias atenuantes, de consideração obrigatória, não permitem a fixação da reprimenda em parâmetros inferiores ao mínimo legal, não havendo confundi-las com as causas de diminuição de pena, que, estas sim, ensejam essa possibilidade". (RJD 23/299)

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

Valdiley é primário e não ostenta maus-antecedentes criminais.

Verificada a ininterestadualidade da traficância, observando que Valdiley confessou a prática delitativa, detalhadamente, bem como as circunstâncias do delito, o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 será aplicado na proporção de 1/6.

É pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.887.511-SP, que fixou diretrizes acerca da consideração da quantidade e variedade de entorpecentes na dosimetria da pena.

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminoso ou à integração a organização criminoso. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença” (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim, tratando-se de agente primário, a redução deve se dar em seu grau máximo, ou seja, 2/3, conforme o preconizado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo, a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados pelo valor mínimo.

Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231. Não outras há atenuantes ou agravantes. Pela incidência do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, aumento a reprimenda em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Aplicado o § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, diminuo a pena em 2/3, totalizando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados na base. Não há outras causas de diminuição ou de aumento.

À míngua de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva.

Em face do disposto no artigo 33, alínea c, do Código Penal e artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixo o regime inicial aberto. Por força da Resolução 5/2012 do Senado Federal, não havendo óbice, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade, por igual prazo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO VALDILEY CARREIRO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo nacional à A.A.C.D./Osasco-SP e prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, por incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do quantum da reprimenda aplicada, e da substituição levada a efeito, poderá Valdiley recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE de imediato o competente ALVARÁ de SOLTURA clausulado.

Eventual detração penal incumbe ao Juízo da Execução Criminal.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente nos termos regimentais.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 27 de maio de 2022.